

1526329-72.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANA LUCIA SCHMIDT RIZZON

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VII - Itaquera

Vara: Vara Criminal e do Juizado Especial Criminal do Foro Regional de Itaquera

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... daria vida à atividade ilegal do tráfico, e por isso sua conduta mereceria reprovação legal e responsabilização penal.

Levanta-se assim a tese de que, sem o consumo de drogas, não poderia haver o tráfico. Não se tem o objetivo de negar ou confirmar essa tese nesta decisão. É caso apenas de se discutir se, ao proteger o bem jurídico pretendido - a saúde e incolumidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VII - Itaquera

Vara Criminal e do Juizado Especial Criminal do Foro Regional de Itaquera

Avenida Pires do Rio, 3915, São Paulo - SP - cep 08240-095

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1526329-72.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526329-72.2020.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

WALTER ZUSA CASTELANI e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA LUCIA SCHMIDT RIZZON

Vistos.

WALTER SUZA CASTELANI, RG 53985804-SP, nascido em 02/02/1999, demais qualificações nestes autos, foi denunciado por ter, em tese, infringido o disposto no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Relatório dispensado nos termos do artigo 81, §3º, da Lei 9.009/1995.

Fundamento e decido.

O pedido condenatório é improcedente.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de Walter Suza Castelani por trazer consigo, em tese, a substância psicoativa como "maconha", em desacordo com a legislação nacional.

Em audiência de instrução, Camila Costa Neves, testemunha, policial militar, afirma que fazia policiamento a pé. Que resolveu abordar o réu e que, em busca pessoal, encontraram drogas. Disse não se lembrar da quantidade encontrada. Disse que era maconha, e que foi encontrada no bolso do réu. Que o local em questão é conhecido como ponto de tráfico. Que o réu afirmou, na data, que era para uso próprio. Perguntada, disse não se recordar exatamente da quantidade de drogas encontrada.

Em primeiro lugar, deve-se considerar que, dada a quantidade de substância (cocaína) encontrada, o fato é atípico. O Laudo Pericial de fls. 16-18 detectou que o réu, conjuntamente com outro sujeito, estava em posse de 7,8 gramas de maconha; tem-se, assim, que haveria algo em torno de 3,9 gramas de cocaína para cada um dos sujeitos envolvidos, o réu e mais um companheiro seu.

Ora, o direito penal, na avaliação de condutas merecedoras de responsabilização e consequente penalização, não deve apenas avaliar a adesão abstrata do fato à norma, mas sua relevância social e significância. O Supremo Tribunal Federal tem atribuído ao princípio da insignificância um papel importante na caracterização dos tipos penais. No Habeas Corpus 96.827/RS, o Ministro Relator Celso de Mello assim estabeleceu os critérios para aferição dos vetores do postulado do princípio da insignificância: a mínima ofensividade da conduta, a nenhuma periculosidade da ação, o reduzido grau de reprovabilidade social do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica comprovada.

Não se nega que o consumo de drogas ilícitas seja assunto sujeito a muitas opiniões, polarizações e debates de cunho filosófico, político e religioso. É fato, no entanto, que o consumo e posse de pequenas quantidades de drogas como a maconha são atos sociais corriqueiros, em especial na vida noturna de cidades grandes. Não se nega que, do ponto de vista da saúde individual, o consumo dessa droga certamente é reprovável e trará, cedo ou tarde, consequências fisiológicas ao réu. No entanto, é de se questionar se a quantidade por ele trazida é merecedora da atenção e reprovação do direito penal, sabidamente a última ferramenta, última ratio do cabedal jurídico e o mais gravoso dos direitos sancionadores. A conduta em si, neste caso, é de pouca relevância para o direito penal, vez que o réu, ao portar pequena quantidade de maconha em seus bolsos, que pretendia consumir posteriormente, praticava conduta de ofensividade social diminuta e que dispensa a rigidez do tratamento penal.

Embora formalmente típico o fato descrito na denúncia, a teor da prova referida trazida ao feito, ele não apresenta nenhuma relevância material, por absoluta incapacidade de produzir um resultado que gere qualquer ameaça à incolumidade pública.

Mais do que isso, diferentemente de decisões anteriores proferidas por este juízo, coadunamos com entendimentos recentes emanados pelo Supremo Tribunal Federal de que o tipo previsto no artigo 28 da Lei 11.343 de 2006 é inconstitucional.

Assim está descrita a conduta prevista no referido artigo: "Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas".

Ora, a norma em questão tem como fito, pela via do direito penal, proteger a saúde pública. Parte-se do pressuposto de que o usuário de drogas, ao comprá-las e consumi-las, daria vida à atividade ilegal do tráfico, e por isso sua conduta mereceria reprovação legal e responsabilização penal.

Levanta-se assim a tese de que, sem o consumo de drogas, não poderia haver o tráfico. Não se tem o objetivo de negar ou confirmar essa tese nesta decisão. É caso apenas de se discutir se, ao proteger o bem jurídico pretendido - a saúde e incolumidade públicas -, o legislador não teria, por outro lado, violado outros direitos fundamentais do sujeito, como sua intimidade e privacidade. Neste caso, parece assistir razão ao Ministro Gilmar Mendes, que em seu relatório ao Recurso Extraordinário 635659/São Paulo, argumentou:

É sabido que as drogas causam prejuízos físicos e sociais ao seu consumidor. Ainda assim, dar tratamento criminal ao uso de drogas é medida que ofende, de forma desproporcional, o direito à vida privada e à autodeterminação. O uso privado de drogas é conduta que coloca em risco a pessoa do usuário. Ainda que o usuário adquira as drogas mediante contato com o traficante, não se pode imputar a ele os malefícios coletivos decorrentes da atividade ilícita. Esses efeitos estão muito afastados da conduta em si do usuário. A ligação é excessivamente remota para atribuir a ela efeitos criminais. Logo, esse resultado está fora do âmbito de imputação penal. A relevância criminal da posse para consumo pessoal dependeria,

assim, da validade da incriminação da autolesão. E a autolesão é criminalmente irrelevante. (O grifo é nosso)

Os argumentos acima mencionados podem ser perfeitamente aplicados ao caso que ora se analisa. O réu estava em posse de pequena quantidade de droga e dela iria fazer uso pessoal. Não são pequenos os efeitos do uso dessa substância sobre o corpo e a vida do réu. No entanto, essas ações ainda estão na alçada de sua intimidade e de seus direitos de personalidade. São incapazes de atingir, por elas mesmas, a incolumidade ou a saúde pública.

A conexão do consumo de uma pequena quantidade de THC com todos os mecanismos do tráfico de drogas é remota, e punir o usuário por meio do direito penal torna-se excessivamente gravoso à sua intimidade e privacidade, corolários dos seus direitos fundamentais (art. 5º, inciso X, da Constituição Federal). Entendendo inconstitucional a penalização do consumo e posse de drogas por usuários, entendo, assim, como atípica a conduta do réu.

Por todo o exposto, é de rigor a sua absolvição.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva e ABSOLVO WALTER SUZA CASTELANI da imputação prevista no art. 28 da Lei 11.343 de 2006 com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Proceda-se às comunicações e anotações de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

São Paulo, 12 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA